

***SALAHUHUDIN GHAFFAR @ GAVIN EDWARD O'LAUNAIHG***  
***lwn***  
***SERINA BINTI REDZUAWAN***

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, ), YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel)]

**Pada : 17hb Oktober 2018**

**Kes Semakan No. 10000-003-0077-2018**

**Peguam Pemohon:** Dato' Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar dari Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir

**Peguam Responden: -**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

**PERMOHONAN**

[1] Pemohon Salahudin Ghaffar @ Gavin Edward O'launaigh telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-075-0276-2018 (Permohonan

Untuk Mendapatkan Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab) yang bertarikh 21hb Mei 2018.

## **FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR**

[2] Pihak-pihak telah berkahwin pada 1hb Januari 2010 di Kuala Lumpur dan telah bercerai pada 1hb Ogos 2017 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling, Selangor. Hasil perkahwinan pihak-pihak telah mendapat dua (2) orang anak.

[3] Pada 27hb Julai 2017, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memberikan suatu Penghakiman Persetujuan Pihak-Pihak berhubung hak jagaan anak-anak melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10300-028-0333-2017.

[4] Dalam Penghakiman Persetujuan berhubung hak jagaan anak sementara tersebut, hak jagaan telah diberikan kepada Pemohon. Perintah Persetujuan hak jagaan tersebut juga mengandungi syarat-syarat hak jagaan yang dibuat berdasarkan seksyen 88 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*]. Syarat-syarat bagi Perintah Persetujuan tersebut antara lainnya menyatakan seperti berikut;

- a) Mahkamah memerintahkan anak-anak tersebut tidak dibenarkan tidur di rumah bapa kandung Responden tanpa

kehadiran Responden atau pembantu rumah dan anak-anak tersebut mestilah tidur berasingan dari bilik bapa Responden; dan

- b) Mahkamah memerintahkan Responden tidak dibenarkan memburukkan, memperlekehkan dan mengungkit secara langsung atau tidak langsung di media social berkenaan keluarga terdahulu (Gavin, Serina, Tristan, Isabella)

[5] Pada 17hb April 2018, Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab bagi memulakan prosiding tindakan pengkomitan terhadap Responden. Permohonan tersebut telah dipohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan subperenggan 151(1) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*].

[6] Perayu dalam permohonannya dibawah subperenggan 151(1) (aa) [*Enakmen 4 Tahun 2003*], di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor menyatakan bahawa Responden telah tidak mematuhi kedua-dua terma perintah seperti yang dinyatakan pada perenggan [5] di atas.

[7] Prosiding perbicaraan permohonan Pemohon untuk Mendapatkan Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab terserhadap Responden ebut telah dibuat secara *ex parte* dan pada

21hb Mei 2018 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak permohonan Pemohon tersebut.

[8] Seterusnya, berikutan dengan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang menolak permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memohon agar Perintah/Penghakiman tersebut disemak oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Pemohon pada 14hb Jun 2018 telah memfailkan Notis Permohonan Semakan ini yang antara lainnya memohon;

- a) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 53(1)(2) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung perintah/keputusan YA Hakim Bicara bertarikh 21hb Mei 2018 bersamaan 5 Ramadhan 1439H di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui permohonan Kes Permohonan No.: 10200-075-0276-2018;
- b) Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan bagi kes No. Permohonan: 10200-075-0276-2018;
- c) Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[9] Dalam menyokong permohonan ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 13hb Jun 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- a) Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah di dalam membuat penghakiman melibatkan Permohonan No.: 10200-075-0276-2018 dalam menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab sedangkan tahap pembuktian bagi permohonan kebenaran mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab adalah hanya bersifat *Prima Facie* di atas prinsip imbangan kebarangkalian '*balance of probabilities*';

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR**

[10] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Permohonan No.: 10200-075-0276-2018 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 10 Afidavit Pemohon.

[11] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

*“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada*

*mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan*

[12] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/ penghakiman/ perintah Mahkamah Tinggi Syariah.

[13] Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan”.

[14] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah

menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

*“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”*

[15] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no. 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
  - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
  - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[16] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[17] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Sokongan Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Permohonan No: 10200-075-0276-2018, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut bertentangan dengan prinsip semakan dengan alasan seperti berikut;

- a) Prosiding Kes Permohonan No: 10200-075-0276-2018 telahpun selesai dan keputusannya permohonan tersebut telah pun diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut pada prinsipnya boleh dirayu. Oleh kerana keputusan tersebut boleh dirayu, dan Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak. Ianya bertujuan



untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan proses mahkamah "*Abuse of court process*" oleh pihak-pihak. (P. 4, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014); dan

- b) Terdapat salah arah undang-undang telah dilakukan oleh Pemohon di dalam membuat permohonan ini dengan menyatakan bahawa permohonannya ini dibuat berdasarkan seksyen 53 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami tidak menemui apa-apa undang-undang yang dimaksudkan oleh Pemohon sedang berkuatkuasa di Negeri Selangor ini.

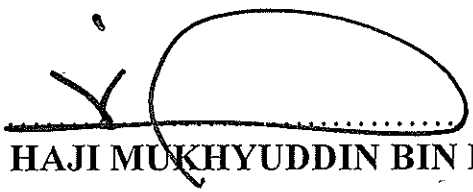
[18] Oleh yang demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan Pemohon ini.

## KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Pemohon dan Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 13hb Jun 2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i ] Permohonan Pemohon ditolak;

Ditandatangani oleh:-



1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



3. **Y.A DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : .....